

<제1장 노동법 총론.제5절 노조법상 근로자>

I. 의의[노조법 제2조 제1항]

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제2조 제1항은 근로자를 직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자라고 정의한다. 이 노조법상 근로자 개념은 개별적 근로관계법인 근로기준법상 근로자 개념보다 더 넓은 범위의 노무 제공자를 포함하는 특징을 가진다. 이는 노동 3권을 보장하고 근로자의 단결권을 실질적으로 확대하기 위한 입법적 특수성 때문이다.

II. 입법목적

- 노조법의 근로자 개념은 헌법이 보장하는 근로 3권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권)을 보호하고 실현하는 것을 주된 목적으로 한다. 개별 근로계약의 보호에 초점을 맞추는 근로기준법과는 달리, 노동조합을 결성하고 운영하며 단체교섭을 통해 사용자와 대등한 관계를 형성할 수 있는 주체를 정의한다. 따라서 경제적 약자로서 집단적 보호가 필요한 자는 사용자의 지휘·감독 여부와 관계없이 포함시키려는 확대적인 취지를 가진다.

III. 노조법상 근로자의 개념

1. 직업의 종류를 불문

- 근로기준법과 동일하게 육체 노동이든 정신 노동이든, 정규직이든 비정규직이든 고용 형태나 직업의 종류에 구애받지 않고 실질적인 노무 제공 관계에 따라 판단된다. 이는 특정 직업에 대한 차별 없이 단결권을 보장하기 위함이다.

2. 임금·급료 기타 이에 준하는 수입

- 노조법의 수입 개념은 근로기준법상 임금보다 광범위하다. 임금이나 급료는 물론, 이에 준하는 수입(예 : 수수료, 용역 대가, 커미션 등)까지 포함한다. 이는 계약 형식이 도급이나 위임이더라도 실질적으로 노무 제공의 대가로서 생활을 유지하는 데 사용되는 모든 경제적 급부를 포괄함으로써 근로자 범위를 확대하는 역할을 한다.

3. 그에 의하여 생활하는 자

- 이 요건이 노조법상 근로자의 범위를 확대하는 핵심 근거이다. 특정 사용자에게 전속되어 사용종속관계가 엄격하게 인정되지 않더라도, 노무 제공을 통해 얻는 수입에 주로 의존하여 생활하는 경제적 약자라면 노조법의 보호를 받을 필요가 있다는 관점이 반영된 것이다. 이로써 특수형태근로종사자와 같이 독자적인 사업자로 분류되기 쉽지만, 사용자와 대등한 교섭력이 없는 노무 제공자들도 노조법상 근로자로 포섭할 수 있는 기반이 된다.

IV. 대법원의 근로자성 판단기준

1. 종전 판례

- 종전 대법원 판례는 노조법상 근로자의 판단 기준에 있어서도 근로기준법상의 사용종속성을 주된 기준으로 원용하는 경향을 보였다. 즉, 노무 제공자가 사용자의 상당한 지휘·감독을 받는지, 근무 시간과 장소가 구속되는지 등 인격적 종속성을 중시하였다. 이로 인해 특수형태근로종사자들은 계약 형식이나 업무 수행의 자율성을 이유로 노조법상 근로자로 인정받기 어려운 경우가 많았다.

2. 최근 판례★

- 최근 대법원 판례는 노조법의 확대된 입법 목적을 적극적으로 반영하여 판단 기준을 완화하였다. 노조법상 근로자는 근로기준법상 근로자와 달리, 사용종속성의 징표 중 인격적·기술적 종속성보다는 경제적·조직적 종속성을 중심으로 종합적으로 판단해야 한다고 명확히 하였다.

(1) 경제적 종속성

- 노무 제공자가 자신의 수입으로 생활하는지, 특정 사용자에게 노무를 제공하는 것이 주된 수입원인지, 독자적으로 사업 경영을 하여 이윤 창출이나 손실 위험을 부담하는지 여부 등 경제적 지위를 중요하게 본다.

(2) 조직적 종속성

- 노무 제공자가 특정 사용자의 사업 조직에 실질적으로 편입되어 운영되는지, 사용자가 노무 제공자의 업무를 전체적으로 지배하고 통제하는지 여부 등 조직 차원의 종속성을 중요하게 본다.

(3) 단결권 보장 필요성

- 노무 제공자가 사용자와 대등한 교섭력을 갖지 못하여 단결권을 통한 집단적 보호가 절실하게 필요한 지위에 있는지 여부를 판단에 반영한다.

3. 검토

- 최근 판례의 태도 변화는 노조법상 근로자 개념이 근로기준법상 근로자 개념과 분리되어 독자적인 의미를 갖는다는 것을 명확히 하였다. 이는 급변하는 노동 시장 환경에서 노무를 제공하는 다양한 근로자들의 단결권을 폭넓게 보호하고 노사 관계의 집단적 균형을 도모하려는 시대적 요구를 수용한 것으로 평가된다.

V. 구직자·실업자·퇴직자(해고자)의 근로자성

1. 문제점

- 노조법상 근로자는 노무 제공을 통해 수입을 얻어 생활하는 자를 원칙으로 하므로, 현재 노무 제공 관계가 종료된 실업자나 퇴직자(해고자), 또는 아직 노무 제공 관계가 시작되지 않은 구직자가 노조법의 보호를 받는 근로자로 인정될 수 있는지 여부가 쟁점이 된다.

2. 종래 논의[구 노조법 제2조 제4호 라목 단서]

- 구 노조법 제2조 제4호 라목 단서는 다만, 해고된 자가 노동위원회에 부당노동행위의 구제신청을 한 경우에는 중앙노동위원회의 재심판정이 있을 때까지는 근로자가 아닌 자로 해석하여서는 아니 된다.고 규정하여, 구제 신청이라는 특정 행위를 전제로 근로자성을 제한적으로 인정했기 때문에 단결권의 본질을 침해한다는 비판과 논란이 있었다.

3. 검토

- 현행법과 판례는 노조법의 목적이 단결권 보장에 있음을 최우선으로 한다. 따라서 구직자는 근로 관계가 현실화되지 않아 노조법상 근로자로 보기 어렵다는 것이 일반적이다. 그러나 해고자의 경우, 해고가 노조 활동을 이유로 한 부당노동행위로서 다투어지고 있는 경우에는 단결권을 실질적으로 보장하기 위해 해고의 효력이 확정되기 전까지 노조법상 근로자성을 인정한다. 또한, 일반적인 실업자라도 재취업을 위해 결성한 노동조합에 가입하는 등 집단적 노동 관계의 주체로서 활동하는 경우 노조법상 근로자로 인정받을 수 있다. 이는 노동자의 단결권을 확대하는 헌법적 요청에 따른 것이다.

VI. 불법체류외국인의 근로자성

1. 범위반 근로관계의 사법상 효력

- 외국인이 출입국관리법을 위반하여 취업 활동을 하는 경우, 이는 공법상 위법한 행위가 된다. 그러나 판례는 공법상의 위법성이 근로계약의 사법상 효력을 직접적으로 무효로 만들지는 않는다고 본다. 즉, 노무 제공의 대가로서의 임금 청구권 등은 근로기준법에 따라 보호받아야 한다고 본다.

2. 노조법상 근로자성

- 노조법은 근로자의 정의에서 국적을 차별하거나 제한하는 규정을 두고 있지 않다. 따라서 불법체류외국인이라 하더라도 노무 제공을 통해 수입을 얻어 생활하는 실질적인 경제적 종속성이 인정된다면, 노조법상 근로자로 인정된다. 이는 단결권이 인간의 기본권으로서 외국인에게도 인정되며, 노동관계에서의 실질적인 약자를 보호하려는 노조법의 입법 목적에 부합한다. 따라서 불법체류외국인도 노동조합을 결성하거나 가입하고 단체 활동을 할 수 있는 주체가 될 수 있다.

VI. 결론

- 노조법상 근로자는 근로기준법상 근로자보다 넓은 범위를 포괄하며, 이는 근로 3권 보장이라는 노조법의 입법 목적에 기인한다. 대법원의 최근 판례는 사용종속성 판단에서 인격적·기술적 종속성보다는 경제적·조직적 종속성을 중요하게 다루어 단결권을 확대하였다. 또한, 해고자의 경우에도 노조 활동을 이유로 한 부당노동행위와 관련하여 다투어지는 경우에는 근로자성이 인정되어 노조 활동의 주체가 될 수 있다. 불법체류외국인 역시 국적이거나 체류 자격의 위법성과 별개로 경제적 종속성에 따라 노조법상 근로자로 인정되어 단결권을 보호받는다. 이처럼 노조법상 근로자 개념은 집단적 노사 관계에서 실질적인 약자를 포섭하여 노동 관계의 자주적 조정을 가능하게 하는 법적 기초가 된다.